

<입문-제6장 행정행위.제1절 행정행위 일반>

I. 행정행위와 처분 등

1. 행정행위의 개념

- 행정행위란 행정청이 구체적 사실에 관하여 법 아래서 행하는 권력적 단독 행위로서, 직접적으로 법적 효과를 발생시키는 행위를 말한다. 이는 행정법학에서 가장 중요하고 전통적인 개념 중 하나로, 행정청의 다양한 행위 중 국민의 권리·의무에 직접적인 변동을 가져와 사법 심사의 대상이 되는 행위를 포괄적으로 지칭하는 데 사용되어 왔다. 행정행위의 개념은 독일 공법학에서 유래하였으며, 한국 행정법학에서도 오랫동안 항고소송의 대상인 처분을 해석하는 기본 틀로 활용되었다. 행정행위는 법적 안정성과 예측 가능성을 확보하는 기능을 하며, 공정력, 구속력, 집행력 등 특별한 효력을 갖는다는 특징이 있다.

2. 처분과의 구별

- 행정행위와 처분은 밀접하게 관련되지만, 그 의미와 범위는 구별된다.

(1) 개념의 연혁적 구별

- 행정행위는 독일 공법학에서 발전한 학문상의 개념으로, 행정작용의 법적 성격을 분류하기 위한 도구적 개념이다. 반면, 처분은 행정소송법 제2조 제1호에 규정된 실정법상의 개념으로, 행정소송의 대상이 되는 행정작용을 지칭한다.

(2) 범위의 구별 및 확대

- 전통적으로는 행정행위가 곧 처분으로 인식되어 왔으나, 현대 행정소송법의 발전과 함께 처분의 범위가 행정행위의 범위를 초월하여 확대되는 경향을 보인다. 법원은 행정의 다양성과 복잡성을 고려하여, 전통적인 행정행위 개념으로는 포섭되지 않더라도 국민의 구체적인 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 공권력적 행위라면 그 밖에 이에 준하는 행정작용에 해당한다고 보아 처분성을 인정한다. 따라서 행정행위는 처분의 핵심이자 주된 형태이지만, 처분의 개념이 행정행위보다 더 넓은 범위를 포괄하는 상위 개념으로 이해된다.

II. 행정행위의 개념적 요소

- 행정행위로 인정되기 위해서는 다음과 같은 요소를 충족하여야 한다. 이는 행정소송법상 처분의 개념을 이해하는 데 기초가 된다.

1. 행정청이 행하는 것

- 행정행위는 행정주체의 의사를 결정하고 외부에 표시할 권한을 가진 행정청이 행하는 행위여야 한다. 여기서 행정청이란 국가 또는 공공단체의 기관 중에서 행정사무를 자기의 이름으로 처리할 수 있는 권한을 가진 기관을 말한다. 행정청의 보조 기관이나 하부 기관이 행하는 행위는 원칙적으로 행정행위가 아니다.

2. 구체적 사실에 관한 것

- 행정행위는 특정 개인이나 사건과 같은 구체적인 사실에 대하여 행해지는 행위여야 한다. 일반적인 성질을 가진 모든 사람에게 적용되는 추상적이고 일반적인 규율인 법규 명령이나 행정규칙 등은 행정행위가 아니다. 행정행위는 법규의 일반성을 개별적인 구체성으로 전환시키는 법 집행 작용이다.

3. 법적 행위일 것

- 행정행위는 행정청의 의사 표시를 통해 직접적으로 법적 효과를 발생시키는 행위, 즉 법적 행위여야 한다. 단순한 통지, 안내, 정보 제공 등 법적 효과 없이 사실적인 효과만을 발생시키는 사실 행위는 원칙적으로 행정행위가 아니다. 다만, 권력적 사실 행위와 같이 국민의 권리·의무에 중대한 영향을 미치는 경우에는 예외적으로 처분성이 인정될 수 있다.

4. 권력적·단독적인 공법행위일 것

(1) 권력적 공법 행위

- 행정행위는 행정청이 우월한 공권력의 주체로서 일방적으로 국민에게 의무를 부과하거나 권리를 제한하는 권력적인 성격을 가져야 한다. 사인(私人)과의 대등한 지위에서 체결하는 공법상 계약이나 사법상 행위는 행정행위가 아니다.

(2) 단독 행위

- 행정행위는 행정청이 상대방의 동의 여부와 관계없이 일방적인 의사 표시로 법적 효과를 발생시키는 단독 행위여야 한다. 상대방의 신청이나 동의를 받아 비로소 성립하는 행위도 행정청의 의사가 핵심이 된다는 점에서 단독 행위로 본다.

5. 거부행위

- 행정청의 거부 행위는 소극적인 행위이지만, 특정한 요건을 충족할 경우 예외적으로 행정행위(처분)로 인정된다. 거부 행위가 처분으로 인정되기 위해서는 다음과 같은 요건을 갖추어야 한다.

(1) 법규상 또는 조리상 신청권 존재

- 국민에게 법규상 또는 조리상 신청권이 존재하여야 한다. 신청권이 없는 경우 행정청이 거부하더라도 국민의 권리·의무에 영향을 미치지 않으므로 처분이 될 수 없다.

(2) 법률 관계의 직접적 변동

- 그 거부 행위가 신청인의 법률 관계에 직접적인 변동을 초래하여야 한다. 즉, 신청의 이행을 거부함으로써 신청인에게 불이익이 발생하여야 처분성이 인정된다. 이러한 거부 행위는 소극적 처분으로서 취소소송의 대상이 된다.

III. 행정행위의 분류 기준에 따른 종류

- 행정행위는 다양한 기준에 따라 분류될 수 있으며, 이러한 분류는 각 행정행위의 법적 성격과 효력을 이해하는 데 도움을 준다.

1. 행정행위 대상에 따른 구분

(1) 대인적 행정행위

- 상대방의 지식·학식·기술 등 주관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다. 인간문화재지정, 운전면허, 의사면허 등이 이에 해당한다. 대인적 행정행위의 효과는 일신전속적인 것이므로 제3자에게 승계되지 않는다.

(2) 대물적 행정행위

- 그 행위의 대상인 물건이나 시설의 객관적 사정을 고려하여 행해지는 행정행위이다. 차량검시합격 처분, 건축물 준공검사, 채석허가, 건물철거 명령 등이 이에 해당한다. 대물적 행정행위의 효과는 명문규정이 없더라도 제3자에게 이전될 수 있다(다수설, 판례).

(3) 혼합적 행정행위

- 상대방의 주관적 사정과 함께 행정행위의 대상인 물건, 시설의 객관적 사정을 모두 고려하여 행하여지는 행정행위를 말한다. 전당포영업허가 등이 이에 해당한다. 혼합적 행정행위의 이전은 명문의 규정이 있는 경우에 인정되며, 일반적으로 행정청의 승인 또는 허가 등을 받도록 하고 있다.

2. 행정행위 내용에 따른 구분

(1) 법률행위적 행정행위

- 행정청의 의사 표시 내용대로 법적 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. 행정행위의 대부분이 여기에 속하며, 다시 명령적 행위(허가, 하명, 면제)와 형성적 행위(특허, 대리, 인가)로 나뉜다.

(2) 준법률행위적 행정행위

- 행정청의 의사 내용과는 관계없이 법률이 그 행위에 부여한 효과가 발생하는 행정행위를 말한다. 예를 들어, 공증, 통지, 수리, 확인 등이 이에 해당한다.

3. 법률효과의 성질에 따른 구분

(1) 수익적 행정행위

- 국민의 권리나 이익을 부여하거나 확대하는 등 국민에게 유리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다. (허가, 특허)

(2) 침익적 행정행위

- 국민의 권리나 이익을 제한하거나 의무를 부과하는 등 국민에게 불리한 법적 효과를 가져오는 행정행위를 말한다. (영업 정지, 과세 처분)

(3) 복효적 행정행위(제3자효 행정행위)

- 하나의 행정행위가 특정인에게는 수익적 효과를, 제3자에게는 침익적 효과를 동시에 발생시키는 행정행위를 말한다. (경쟁 업체에 대한 특허 부여)

4. 법적 구속의 정도에 따른 구분

(1) 기속 행위

- 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되면 반드시 그에 따른 행위를 해야 하며, 재량의 여지가 없는 행위를 말한다. 행정청의 의사가 개입될 여지가 없으므로, 위법성 판단 시 법원의 심사 밀도가 높다.

(2) 재량 행위

- 행정청이 법규에 정해진 요건이 충족되더라도, 행위 여부나 내용을 스스로 선택할 수 있는 판단의 자유가 있는 행위를 말한다. 재량 행위의 심사는 원칙적으로 재량권의 한계를 넘었거나 남용했는지 여부(일탈·남용)만을 심사한다.

5. 기존의 법률상태에 변동을 가져오는가에 따른 구분

(1) 적극적 행정행위

- 적극적 행정행위는 현재의 법률상태에 변동을 가져오는 행정행위를 말한다. 허가·특허 등이 이에 해당한다.

(2) 소극적 행정행위

- 소극적 행정행위는 현재의 법률상태에 변동을 가져 오지 않는 행정행위를 말한다. 허가·특허 등의 신청에 대한 거부처분이 이에 해당한다.

N. 결론

- 행정행위는 행정청이 구체적 사실에 관하여 법 아래 행하는 권력적 단독 행위로서, 행정법학에서 항고소송의 대상인 처분의 핵심을 이루는 개념이다. 처분은 행정행위 외에 권력적 사실 행위 등을 포괄하는 상위 개념으로 이해된다. 행정행위는 행정청, 구체적 사실, 법적 행위, 권력성, 단독성 등의 개념적 요소를 가지며, 명령적 행위와 형성적 행위, 기속 행위와 재량 행위 등 다양한 기준으로 분류되어 그 법적 효력과 통제 방식이 달라진다. 행정행위 개념에 대한 정확한 이해는 행정소송에서 위법성을 판단하고 국민의 권익을 구제하는 데 필수적인 기초를 제공한다.